

1500110-05.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500110-05.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017241/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 22535856 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 7/22/592 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2017241 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGUINALDO COSTA BARREIROS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 13 dias do mês de abril de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Luana Pereira do Amaral. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) AGUINALDO COSTA BARREIROS, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira e Leonardo Cavalcanti de Oliveira.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Leonardo) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).
Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira.
Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:
Homologo a desistência das partes em relação à testemunha Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira.
"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:
Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:
"MM. Juíza,

AGUINALDO COSTA BARREIROS foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta de 11h41m, na rua Vasco da Gama, nº 273, bairro Pauliceia, nesta cidade e comarca, trazia consigo 11 porções de "crack" e mantinha em depósito 73 porções de "maconha" destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram parcialmente comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente. Se não é certo que a maconha pertencesse ao réu, não há dúvidas quanto às porções de crack em poder do réu e seu destino ao comércio ilícito, fatos suficientes para a procedência da ação.
A autoria e materialidade foram devidamente comprovadas.

Dos fatos:

Segundo se apurou, policiais civis receberam informações de que no local havia "intenso tráfico de drogas" ... e "naquele momento um indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo vulgo "Zóio", seria quem estaria comercializando tais substâncias".

Assim, dirigiram-se ao local delatada, onde avistaram o denunciado defronte à residência. Feita abordagem de praxe, em poder dele foram localizadas 11 porções de "crack", além da quantia de R\$ 69,00 em dinheiro. Instado, informalmente, o denunciado confessou a prática delitativa e alegou que era para sustentar o vício. Em continuidade, diante de informações de que o terreno ao lado da residência do denunciado era utilizado para guardar entorpecentes, os policiais adentraram ao local, onde apreenderam 73 porções de maconha e uma balança de precisão.

Instado, o denunciado negou a propriedade dessa droga e da balança. Perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Com efeito, a testemunha Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira, policial civil, disse "É policial civil e recebeu informações de um morador do bairro Jd Esplanada de que haveria intenso tráfico de entorpecentes naquela vida. O denunciante narrou que naquele momento um indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo vulgo "Zóio", seria quem estaria comercializando tais substância, sendo então prontamente diligenciado naquele local. Com viatura descaracterizada, adentraram a via e observaram AGUINALDO COSTA BARREIROS defronte a sua residência, sendo este prontamente abordado. Realizada busca pessoal, localizaram em seu bolso a quantia de R\$ 69,00 em espécie, além de 11 porções de crack. Questionado, confessou estar realizando a mercancia de drogas naquele local para sustentar seu vício, pois também seria usuário de crack. Como haviam denúncias de um imóvel abandonado que estaria sendo utilizado por traficantes para guardar drogas, sendo este localizado ao lado da residência de AGUINALDO, o depoente ali adentrou e ao realizar minuciosa busca, localizou uma balança de precisão e 73 porções de maconha. Indagado sobre aqueles entorpecentes, AGUINALDO negou serem de sua propriedade, esclarecendo apenas ser responsável pelas drogas tipo crack, localizadas em seu bolso,

esclarecendo que aquele imóvel era acessado por outras pessoas ligadas ao tráfico, porém se negando a prestar quaisquer informações acerca destas, temendo por represálias dos criminosos." (fls. 02).

No mesmo sentido, o policial Leonardo Cavalcanti de Oliveira disse "É policial civil e nesta data foram até o bairro Jd Esplanada checar denúncia de tráfico. As informações recebidas pelo policial MARCELO aportavam que um indivíduo conhecido pelo vulgo "ZÓIO" estaria comercializando drogas naquele local. Foram até o local utilizando viatura descaracterizada e prontamente observaram AGUINALDO COSTA BARREIROS, vulgo "ZÓIO", defronte a sua residência, sendo este abordado. Durante busca pessoal, localizaram em seu bolso a quantia de R\$ 69,00 em espécie, além de 11 porções de crack. Indagado, AGUINALDO alegou ser usuário de crack e que estaria comercializando as drogas para em troca ganhar porções para seu uso e desta forma, sustentar seu vício. Devido haverem denúncias de um imóvel abandonado que estaria sendo utilizado por traficantes para guardar drogas, sendo este localizado ao lado da residência de AGUINALDO, o policial MARCELO realizou buscas naquele local, localizando uma balança de precisão e 73 porções de maconha. Questionado sobre aqueles entorpecentes, AGUINALDO negou serem de sua propriedade, esclarecendo apenas ser responsável pelas drogas tipo crack, localizadas em seu bolso, esclarecendo que aquele imóvel era acessado por outras pessoas ligadas ao tráfico, porém se negando a prestar quaisquer informações acerca destas, temendo por represálias dos criminosos" (fls. 03).

Perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 04).

Em juízo:

o policial Leonardo Cavalcanti de Oliveira narrou que receberam notícias de tráfico no local. Foram ao ponto informado e observaram AGUINALDO COSTA BARREIROS, vulgo "ZÓIO", pessoa que, segundo a notícia, estaria traficando naquele endereço.

Localizaram em seu bolso R\$ 69,00 e 11 porções de crack. AGUINALDO alegou ser usuário de crack e que estaria comercializando as drogas para em troca ganhar porções para seu uso. Tinham notícias também de que o imóvel ao lado era usado por traficantes para guardar drogas. Neste ponto, encontrou uma balança de precisão e 73 porções de maconha. AGUINALDO negou a propriedade destas drogas, dizendo que era responsável apenas pelo comércio de crack. A mãe do réu disse que a casa onde a droga foi encontrada era uma casa abandonada e muitas pessoas guardam droga ali. O réu estava machucado.

Interrogado, o réu disse que estava com o crack, que tinha acabado de comprar para uso próprio. A pessoa de quem comprou fugiu pela casa abandonada quando os policiais chegaram.

Diante do todo apurado há provas suficientes que demonstram que o réu foi autor do delito em questão.

A narrativa dos policiais civis foi firme e uníssona em confirmar que dirigiram-se ao local para verificarem informações de que um indivíduo, com apelido "Zóio", realizava o tráfico no local. Ao chegarem no endereço indicado, os policiais avistaram o réu. Em seu poder foram localizadas 11 porções de crack e a quantia de R\$ 69,00. Instado, informalmente, ele alegou que é usuário de crack e que estava comercializando para manter o vício, mas que apenas estas lhe pertence.

A quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente não deixam dúvidas de que a droga destinava-se à mercancia ilícita. Ademais, o réu foi surpreendido em local conhecido como "ponto de tráfico ilícito de drogas", o que torna evidente a mercancia ilícita.

Há um ponto importante: os policiais disseram que o réu lhes confessou o comércio das porções de crack. E disseram que o réu não devia ser mesmo o responsável pela maconha, por não ter condições físicas de acessar o imóvel onde esta droga foi encontrada.

Logo se vê que os policiais não tem e não tinham intenção de prejudicar o réu.

Fosse o contrário, não salientariam a impossibilidade de o réu ser o responsável pela guarda da maconha.

Não há nada que invalide os depoimentos dos policiais, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso

Os policiais não tinham motivos para incriminá-lo injustamente. Portanto, as porções de maconha não podem ser atribuídas ao réu. Ele negou responsabilidade. E o policial Leonardo confirmou que o local é usado por outras pessoas para a guarda de entorpecentes e que o réu, em razão de ferimentos que trazia em seu corpo, não tinha condições de pular o muro e acessar o imóvel – abandonado – para guardar ou buscar as drogas.

De todo modo, considerando as porções de crack apreendidas com o réu, fato incontroverso, e o destino ao comércio (quantidade e forma de embalagem das porções, confissão informal aos policiais e a própria condição pessoal do réu, pessoa que ostenta envolvimento com o tráfico de drogas), caracterizado o crime de tráfico de drogas.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira-fase a pena deverá ser fixada acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes e reincidência específica.

Pena acima do mínimo legal.

Incabível, a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, diante da quantidade de drogas mantida no local e a reincidência do réu, o que demonstra que o réu é contumaz e não se tratou de uma conduta isolada.

Portanto, ausentes os requisitos para concessão do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Tratando-se de delito assemelhado ao hediondo e tendo-se em conta a necessidade de se individualizar a pena para a adequada prevenção e reprovação, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo o réu iniciar o desconto da pena no regime inicial fechado.

A prisão preventiva do réu deverá ser mantida. Isso porque, os elementos acostados demonstram que ele é contumaz na prática delitiva. Portanto, não se tratou de uma conduta isolada e, colocado em liberdade, voltará a delinquir, até mesmo porque não possui trabalho lícito e faz do crime seu meio de sustento.

Não houve qualquer alteração fática.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal, condenando-se o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343, de 2006.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Aguinaldo Costa Barreiros foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 87-89), no dia 19 de janeiro de 2022, por volta de 11h41m, na rua Vasco da Gama, nº 273, bairro Pauliceia, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Aguinaldo trazia consigo 11 porções de "crack" e mantinha em depósito 73 porções de "maconha" destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, policiais civis receberam informações de que no local havia "intenso tráfico de drogas" ... e "naquele momento um indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo vulgo 'Zóio', seria quem estaria comercializando tais substâncias". Assim, dirigiram-se ao local delatada, onde avistaram o réu defronte à residência. Feita abordagem de praxe, em poder dele foram localizadas 11 porções de "crack", além da quantia de R\$ 69,00 em dinheiro. Instado, informalmente, o réu confessou a prática delitiva e alegou que era para sustentar o vício. Em continuidade, diante de informações de que o terreno ao lado da

residência do réu era utilizado para guardar entorpecentes, os policiais adentraram ao local, onde apreenderam 73 porções de maconha e uma balança de precisão. Instado, o réu negou a propriedade dessa droga e da balança. Interrogado em solo policial, o réu exerceu o direito constitucional ao silêncio (fls. 4).

Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira, policial civil, contou que: “recebeu informações de um morador do bairro Jd. Esplanada de que haveria intenso tráfico de entorpecentes naquela vida. O denunciante narrou que naquele momento um indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo vulgo “Zóio”, seria quem estaria comercializando tais substância, sendo então prontamente diligenciado naquele local. Com viatura descaracterizada, adentraram a via e observaram Aguinaldo Costa Barreiros defronte a sua residência, sendo este prontamente abordado. Realizada busca pessoal, localizaram em seu bolso a quantia de R\$ 69,00 em espécie, além de 11 porções de crack. Questionado, confessou estar realizando a mercancia de drogas naquele local para sustentar seu vício, pois também seria usuário de crack. Como haviam denúncias de um imóvel abandonado que estaria sendo utilizado por traficantes para guardar drogas, sendo este localizado ao lado da residência de Aguinaldo, o depoente ali adentrou e ao realizar minuciosa busca, localizou uma balança de precisão e 73 porções de maconha. Indagado sobre aqueles entorpecentes, Aguinaldo negou serem de sua propriedade, esclarecendo apenas ser responsável pelas drogas tipo crack, localizadas em seu bolso, esclarecendo que aquele imóvel era acessado por outras pessoas ligadas ao tráfico, porém se negando a prestar quaisquer informações acerca destas, temendo por represálias dos criminosos” (fls. 02).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial civil Leonardo Cavalcanti de Oliveira (fls. 03).

Às fls. 34-36, juntada certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 0003374-73.2016.8.26.0451 – furto qualificado – trânsito em julgado para a Defesa em 27/4/2018; autos n.º 0018189-17.2012.8.26.0451 – tráfico de drogas – pena cumprida ou julgada extinta em 10/7/2017).

Às fls. 73-75, laudo de exame da balança apreendida.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 7, laudo de constatação de fls. 10-11, fotografia de fls. 27 e laudo de exame definitivo de fls. 78-80.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Foi ouvido o policial civil Leonardo Cavalcanti de Oliveira. Alegou que no dia dos fatos surgiu uma informação de que zóio estava em frente a sua residência fazendo a venda de entorpecentes. Foram ao local, visualizaram o mesmo na calçada em frente a residência. Com ele tinha 11 pedras de crack e R\$ 69,00. Teria dito que estava traficando para sustentar o seu vício. Recebia como forma de pagamento pedras de crack. Tinham a informação de que em uma residência abandonada guardavam drogas. O Agnaldo disse que essa droga encontrada na casa não era dele, mas sim, e tão somente o crack com ele encontrado. O policial Marcelo já conhecia o réu de outras abordagens. Procuraram no sistema onde era a residência do réu. A residência em que foram encontradas as demais drogas não era do acusado. Mas, sim abandonada. O policial acredita que realmente o acusado não tinha relação com as drogas lá encontradas já que ele estava bem machucado no dia dos fatos e para ingressar na residência seria necessário grande esforço por parte dele e acredita que não o faria.

b) Por fim, foi interrogado o réu Aguinaldo Costa Barreiros. Disse que esta na rua porque tinha ido ao local comprar drogas. Tinha R\$ 65,00. O rapaz que estava com ele, pulou na casa abandonada. Os policiais o abordaram e encontraram 11 pedras de crack que eram para seu uso. Tinha acabado de comprar.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

De rigor a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu

(CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações deles são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, caso se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga e a quantidade de entorpecente apreendida na posse do réu (11 porções de crack) é compatível com o uso de drogas.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas palavras da Eminente Relatora, "No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicasobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista das Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a médica de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS (Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 01 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátrico: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos",

de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína.” (p. 8-9 do Acórdão)”.

Outrossim, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: “A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais” (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder dos acusados se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

“PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo” (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, e mostra-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas e exsurtem algumas consequências.

a) Da absolvição por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição em razão da inconstitucionalidade do referido tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o qual fere o disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: “Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]” (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344).

Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: “O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais” (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereciam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas.

Diante da alegação ora invocada, de rigor seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, com consequente afastamento da imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas e absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Da aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas

Rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Da pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão, ainda que seja apenas a informal.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime diverso do fechado.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...]

indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

No mais, no atual cenário, qualquer decisão que determina o recolhimento de alguém ao cárcere ou a manutenção de uma prisão anteriormente decretada deve ser ponderada à luz da crise sanitária causada pelo COVID-19. Considerando a situação emergencial de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), somada ao fato de que estabelecimentos em que há aglomeração de pessoas privadas de liberdade são muito mais suscetíveis à disseminação de doenças virais, e visando a reduzir ao máximo os riscos advindos de uma possível contaminação por coronavírus, principalmente dos sujeitos ainda protegidos pela presunção de inocência e acusados de crime não

considerados graves, mostra-se imperiosa a concessão do direito de apelar em liberdade, caso o acusado seja condenado.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

AGUINALDO COSTA BARREIROS, qualificado nos autos foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 19 de janeiro de 2022, por volta de 11h41, na rua Vasco da Gama, nº 273, bairro Pauliceia, nesta cidade e comarca, trazia consigo 11 porções de "crack" e mantinha em depósito 73 porções de "maconha" destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo as denúncias, policiais civis receberam informações de que no local havia "intenso tráfico de drogas" ... e "naquele momento um indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo vulgo "Zóio", seria quem estaria comercializando tais substâncias".

Assim, dirigiram-se ao local delatada, onde avistaram o réu defronte à residência. Feita abordagem de praxe, em poder dele foram localizadas 11 porções de "crack", além da quantia de R\$ 69,00 em dinheiro. Instado, informalmente, o réu confessou a prática delitativa e alegou que era para sustentar o vício.

Em continuidade, diante de informações de que o terreno ao lado da residência do réu era utilizado para guardar entorpecentes, os policiais adentraram ao local, onde apreenderam 73 porções de maconha e uma balança de precisão. Instado, o réu negou a propriedade dessa droga e da balança.

Perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio.

Diante das circunstâncias apuradas, confirmação das informações recebidas, localização de droga em porções individualizadas em poder do réu e dinheiro, além de confissão informal, infere-se que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi oferecida (fls. 90/91), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 96/97).

O réu foi notificado (fls. 103) e apresentou defesa prévia, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e alegou inocência (107/110).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência (fls. 123/126). O réu foi citado (fls. 140).

Durante a instrução, foi ouvida 01 testemunha comum, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 07, no laudo de constatação preliminar de fls. 10/11, na fotografia de fls. 27 e no exame químico-toxicológico de fls. 78/80, segundo o qual foi detectada a presença de Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 04).

Em Juízo, o réu afirmou que no dia dos fatos, estava na rua. Tinha R\$ 120,00 e foi comprar 11 porções de crack. Quando a viatura chegou, a pessoa que estava lhe vendendo a droga pulou na residência ao lado. Foi abordado e os policiais encontraram as 11 porções de crack e o dinheiro. Depois, o policial Marcelo pulou na casa ao lado e encontrou a maconha, que não lhe pertencia. O crack era seu, mas a maconha não. Estava ferido, porque tinha apanhado do irmão, em razão do crack que estava usando. As porções de crack eram para seu próprio consumo. É dependente químico. Estava há alguns dias fora de casa. A pessoa que estava consigo é que lhe havia vendido a droga. Ficou com R\$ 65,00 na mão. Assim que recebeu o troco, o carro de cor prata parou ao seu lado. Não ofereceu resistência. Pagou R\$ 55,00 o

crack que adquiriu. Não tinha qualquer relação com a maconha. Faz uso de cocaína e crack.

A autoria foi comprovada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

O policial civil Leonardo Cavalcanti de Oliveira informou que no dia dos fatos, Marcelo recebeu informação no sentido de que "Zóio" estaria na frente da casa dele vendendo drogas. Marcelo já conhecia "Zóio" e procuraram a residência dele no sistema. Foram até o endereço, em viatura descaracterizada. Assim que ingressaram na rua, já deram de frente com o réu, na calçada. Assim que viu o veículo, o réu já foi de encontro para lhes oferecer droga, mas quando viu que eram policiais, já confessou o crime. Ele foi abordado e encontraram 11 porções de crack e R\$ 69,00 em notas fracionadas. Ele informou que estava na prática do tráfico de drogas e, pelo serviço, ele apenas recebia drogas, para seu próprio uso. Havia informações de que numa residência abandonada na mesma rua, havia tráfico de drogas e, em busca nesse imóvel, encontraram 73 porções de maconha. O réu disse que a maconha não lhe pertencia, apenas vendia o crack. A casa abandonada era ao lado da casa do réu e a mãe dele disse que muitas pessoas guardam drogas nesse local. O réu estava bem machucado, quando foi abordado e, por isso, acha que ele não conseguiria acessar a casa abandonada, porque não conseguiria pular o muro. Não conhecia o réu.

Ouvido apenas na Delegacia de Polícia, o policial civil Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira esclareceu que é policial civil e recebeu informações de um morador do bairro Jd. Esplanada de que haveria intenso tráfico de entorpecentes naquela vila. O denunciante narrou que, naquele momento, um indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo vulgo "Zóio", seria quem estaria comercializando tais substância, sendo então prontamente diligenciado naquele local. Com viatura descaracterizada, adentraram à via e observaram Aguinaldo Costa Barreiros defronte a sua residência e prontamente o abordado. Realizada busca pessoal, localizaram em seu bolso a quantia de R\$ 69,00 em espécie, além de 11 porções de crack.

Questionado, ele confessou estar realizando a mercancia de drogas naquele local para sustentar seu vício, pois também seria usuário de crack. Como havia denúncias de um imóvel abandonado, ao lado da residência de Aguinaldo, que estaria sendo utilizado por traficantes para guardar drogas, ali adentrou e, ao realizar minuciosa busca, localizou uma balança de precisão e 73 porções de maconha.

Indagado sobre aqueles entorpecentes, Aguinaldo negou serem de sua propriedade, esclarecendo apenas ser responsável pelas drogas tipo crack, localizadas em seu bolso, esclarecendo que aquele imóvel era acessado por outras pessoas ligadas ao tráfico, porém, se negando a prestar quaisquer informações acerca dessas pessoas, temendo por represálias dos criminosos (fls. 02).

A primeira questão a ser analisada é sobre a posse da droga.

O réu, na fase policial, permaneceu silente. Judicialmente, o réu afirmou que o crack estava com ele e havia sido adquirida naquele momento, mas a maconha não lhe pertencia.

O policial civil narrou que Marcelo recebeu denúncia anônima, no sentido de que pessoa conhecida dos meios policiais com o apelido de "Zóio", estaria na prática de tráfico de drogas, na frente de sua residência. Pelo sistema, conseguiram pesquisar o endereço e foram ao local, com viatura descaracterizada. Ao entrarem na rua, já avistaram o réu na calçada e ele se aproximou da viatura, para oferecer a droga, no entanto, assim que percebeu que era policiais, já confessou que estava na prática do tráfico. Em revista pessoal, com o réu, foram localizadas 11 porções de crack e R\$ 69,00 em dinheiro trocado. Como havia denúncias de que na casa abandonada ao lado da residência do réu também estava sendo utilizado para o tráfico, Marcelo realizou buscas e encontrou 73 porções de maconha e uma balança de precisão.

Informalmente, o réu assumiu a propriedade das 11 porções e disse que as venderia, para sustentar seu próprio vício. Quanto às 73 porções de maconha, ele disse não lhe pertencer, acrescentando que muitas pessoas ingressavam no local. Leonardo acrescentou que o réu estava ferido e não conseguiria acesso à casa abandonada, porque não conseguiria pular o muro, única forma de chegar ao interior do imóvel. Essas são as provas dos autos.

Inicialmente, quanto ao crack, temos apenas uma versão, no sentido de que ele estava na posse do réu.

O policial Marcelo recebeu informação de que, naquele momento, estava ocorrendo a venda de drogas, efetuada por "Zóio" e, no local indicado, encontrou o réu, o que já indica que outras pessoas o tinham visto nessa prática delitiva.

De outro lado, ambos os policiais confirmaram que a droga estava em poder do réu e o depoimento deles foi unânime e seguro e corroborado pela confissão judicial. Por fim, como já vem decidindo a jurisprudência, a palavra de policiais, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal e desde que esteja em consonância com o conjunto probatório.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Não havendo nenhuma prova de que os policiais civis tivessem interesse em prejudicar o réu, deve-se dar crédito ao depoimento seguro e firme das testemunhas. Com efeito, torna-se certo que o réu estava na posse das 11 porções de crack encontradas em seu poder, em revista pessoal.

Quanto à maconha, contudo, entendo que a prova dos autos não é suficiente para definir o envolvimento do réu.

É que, embora tenha confessado que comercializada o crack para sustentar seu vício, o réu negou que a maconha lhe pertencesse. Além disso, a denúncia não descrevia esse terreno como o local onde o réu guardava as drogas, mas sim havia denúncias anteriores com essa informação, sem envolver o réu. De mais a mais, a casa era abandonada e qualquer pessoa conseguiria acessá-la, pulando o muro.

Por fim, Leonardo afirmou que ferido como estava, o réu não teria condições físicas de pular o muro e acessar o interior do terreno da casa abandonada.

Assim, fica certo apenas a existência de 11 porções de crack em poder do réu.

Neste momento processual, a distinção cabível é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da

prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu alegou que a droga era para seu próprio consumo. A prova dos autos afasta essa alegação. Vejamos.

Inicialmente, os policiais receberam uma denúncia anônima da prática de tráfico de entorpecentes, em determinado endereço, que estava sendo realizado pelo réu, apelidado de "Zóio".

Com essas informações e viatura descaracterizada, os policiais civis estiveram no local e encontraram exatamente o réu, já conhecido dos meios policiais pelo referido apelido e, na posse dele, os policiais encontraram as 11 porções de crack e R\$ 69,00 em dinheiro trocado.

A quantidade de droga (11 porções de crack) e sua forma de embalo (em porções separadas) também indica a destinação de consumo alheio, porque os usuários não mantêm essa quantidade consigo, na rua.

A pessoa de quem o réu informou ter acabado de adquirir drogas não foi referida pelas testemunhas, não havendo indicação de que existisse.

Ademais, o réu confessou, informalmente, aos policiais que estava comercializando o entorpecente, para sustentar seu próprio vício.

E a veracidade dos depoimentos policiais pode ser tomada pelo fato de que, encontrada a maconha, os policiais, tanto na fase policial, quanto em Juízo, identificaram que não era possível relacionar o réu à maconha.

Assim, a confirmação da denúncia recebida, a localização da droga em posse do réu, o dinheiro em espécie, a forma de embalagem e a confissão informal revelam que a droga tinha como destino o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câmb. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor, não sendo caso de desclassificação.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu possui antecedente criminal (Certidão de fls. 35 - Processo nº 0018189-17.2012.8.26.0451) de forma que a sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

A reincidência (Certidão de fls. 34 - Processo nº 0003374-73.2016.8.26.0451) acrescerá novo aumento de um sexto: reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias e 680 dias-multa.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 não pode ser aplicada, em razão da reincidência e maus antecedentes.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

A pena privativa da liberdade cominada ao delito de tráfico de entorpecente há de ser cumprida em regime inicial fechado, uma vez que o delito de tráfico de entorpecentes continua sendo crime equiparado aos hediondos. Ademais, o réu é reincidente, demonstrando que as penas anteriores não foram suficientes para afastá-lo da delinquência.

Pena final: reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, diária-mínima.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR AGUINALDO COSTA BARREIROS, qualificado nos autos, nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, diária-mínima.

Dado o montante de pena, o réu não faz jus à substituição da pena